

1500062-46.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... disse que era o primeiro dia no tráfico trabalhando para o Giovani. A cerca de 150 ou 200m m do local tem uma escola Jetro Vaz de Toledo. Nessa escola, uma das maiores reclamações é que o tráfico ocorria próximo dali. O local é ponto de passagem dos alunos dessa escola. Esse escadão é um dos principais acessos da via pública para o interior da comunidade. Ambos admitiram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500062-46.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2006933/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22338039 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 75/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2006933 - 02º D.P. PIRACICABA, 75/22/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2006933/2022 - 02º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI MATHEUS GONCALVES e outro

Réu Preso

Contr. nº 2022/000042

Aos 21 de março de 2022, às 14:50 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presentes os réus GIOVANI MATHEUS GONÇALVES e JOANDERSON CORREA NOVA (ambos presos CDP Piracicaba). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente o(a) defensor(a) Dr(a). Danilo Carboni, o qual foi constituído nessa audiência. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMS GILMAR PEREIRA DA COSTA e Roberto Carlos Rocha Messias. Ausentes a(s) testemunha(s) de defesa: Sabrina Talita Soares e Jéssica Cristina Sabino.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada às defesas oportunidade para entrevistas reservadas com os acusados e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre os réus e suas defesas.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PM Roberto) e em seguida os interrogatórios dos réus foram captados e gravados em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e as Defesas pelos mesmos foi dito que desistiam das oitiva(s) da(s) testemunha(s) (PM Gilmar, Sabrina e Jessica), o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).GIOVANI MATHEUS GONÇALVES e JOANDERSON CORREA NOVA, estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 00h50min, na Rua Lins, nº 209, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, previamente ajustados, traziam consigo, para fins de tráfico, 6,9g de cocaína, distribuídos em 23 eppendorfs, 24,7g da mesma droga, distribuídos em 108 eppendorfs, e 44,6g de Cannabis sativa L., distribuídos em 46 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 128/131).

O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. Em seu interrogatório, Giovanni negou a prática do tráfico. Disse que estava apenas com parte das drogas que seriam destinadas a seu uso. No mesmo sentido o interrogatório de Joanderson. Suas negativas restaram isoladas nos autos. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo laudo a fls. 141/143, fotos a fls. 36/44 e a foto de exibição e apreensão constante a fls. 14/17. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o policial relatou, na fase informativa (fls. 04), que "estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se depararam com dois indivíduos que, ao notarem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga a pé. Que, após breve perseguição, ambos foram abordados e identificados como sendo as pessoas de JOANDERSON e GEOVANI. Que, com esse, foram localizados 108 porções de substância análoga à COCAÍNA ('pinos' verdes), um celular e, ainda, a quantia de R\$ 90,00. Que, já na posse daquele, dentro da bolsa que trazia consigo, foram encontrados 23 invólucros, de cores preta e rosa, contendo aparentemente COCAÍNA; 46 porções de MACONHA; e a quantia de R\$ 49,00. Que, indagados separadamente, ambos confessaram a prática do narcotráfico".

Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que já fez diversas prisões no local. Disse que Se prendem de manhã, à noite já há outras pessoas vendendo drogas ali. O escadão, onde estavam os réus, dá acesso à comunidade pantanal. Giovanni se identificou como o dono do ponto local e Joanderson disse que era o primeirio dia no tráfico trabalhando para o Giovanni. A cerca de 150 ou 200m m do local tem uma escola Jetro Vaz de Toledo. Nessa escola, uma das maiores reclamações é que o tráfico ocorria próximo dali. O local é ponto de passagem dos alunos dessa escola. Esse escadão é um dos principais acessos da via pública para o interior da comunidade. Ambos admitiram que o dinheiro era proveniente do ilícito. O policial Gilmar, ouvido apenas na fase informativa, corroborou as informações prestadas pelo seu companheiro de farda. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, os réus foram presos em flagrante em conhecido ponto de tráfico, na posse de considerável quantidade de

entorpecentes, bem como de dinheiro trocado. Outrossim, na ocasião, os réus confessaram informalmente a prática delitiva, indicando inclusive que um deles (Giovani) era o gerente do tráfico e o outro (Joanderson) estava começando a trabalhar para o primeiro na venda. Neste panorama, devidamente demonstradas materialidade e autoria delitivas. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que os réus são reincidentes e Joanderson estava em cumprimento de pena (certidões a fls. 57/58 e 50/52, respectivamente), razão pela qual restou claro que se dedicam a atividades criminosas e não fazem jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor do acusado GIOVANI, foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). GIOVANI MATHEUS GONÇALVES foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Recebida a denúncia, o feito teve seu regular trâmite, sendo encerrada a instrução na presente audiência. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a ação penal deve ser julgada improcedente. Excelência, inicialmente é preciso reconhecer que não há provas que permitam concluir, com segurança, que o réu incorreu no crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi atribuído. Isso porque ele negou a prática delitiva e a incriminá-lo só há o relato dos policiais militares, responsáveis por sua prisão em flagrante (Roberto Carlos Rocha Messias e Gilmar Pereira da Costa). Na fase policial, ambos disseram que os acusados estavam em local conhecido pelo tráfico de drogas e que quando perceberam a aproximação da viatura policial, acabaram empreendendo fuga, o que motivou a abordagem. Realizada a revista pessoal, encontraram as drogas descritas na peça acusatória. Judicialmente, foi ouvido apenas o policial Rocha, que trouxe versão idêntica. Acrescentou que ambos confessaram informalmente o tráfico. Ou seja, só foram ouvidos os responsáveis pela sua prisão que, evidentemente, são testemunhas parciais. Afinal, não há como negar que os depoimentos dos policiais militares estão contaminados pela atuação que tiveram na apuração dos fatos, o que gera a necessidade de justificar os atos praticados. Assim, ainda que não estejam impedidos de depor, certo é que seus testemunhos devem ser recebidos com cautela, sobretudo no momento de se conferir o devido valor probatório. Não é por outra razão que em diversas ocasiões já se decidiu pela impossibilidade de se fundamentar uma condenação apenas com base na palavra dos responsáveis pela persecução penal: "As palavras dos policiais merecem credibilidade, mas não basta o título (exercício da função de policial). Há necessidade de que estas tenham apoio em evidências circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável". (TJSP - 7ª Câ. - Ap. Cr. n. 1.465.651/6 - Com. de Campinas - j. 19/5/2005 - v.u.). No mesmo trilho ensina o professor Gustavo Henrique Badaró (os destaques são nossos): "Quanto aos depoimentos dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição

funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma corrente intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranha aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E, no caso sob análise, para além dos depoimentos dos agentes integrantes aos quadros da segurança pública, nenhuma outra prova foi produzida. Na verdade, observa-se que o acusado sequer foi flagrado em ato típico de mercancia. Além disso, chama a atenção a lacônica versão apresentada pelos policiais. Na verdade, a narrativa é semelhante a diversas outras prisões realizadas por policiais militares, que pouco explicam o motivo da abordagem. Não há qualquer investigação aprofundada, não há testemunhas que, de fato, sejam isentas. Não há prisão de qualquer usuário ou imagens de câmeras de segurança. Assim, as provas produzidas contra o réu são bem precárias, ainda mais considerando o crime que lhe é atribuído, equiparado a hediondo. Não se quer dizer que os policiais mentiram, mas apenas que, para a condenação, prova mais robusta é necessária. A propósito, cumpre registrar que quanto mais se dá crédito a esse tipo de prova, mais se incentiva a precariedade de investigações, o que pode dar azo a abusos e manipulações. Dessa forma, por tudo que foi exposto, sendo frágil o conjunto probatório, a Defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Todavia, caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, em caso de condenação pelo crime mais grave narrado na denúncia, requer-se a fixação da pena no mínimo legal, considerando que não houve apreensão significativa de entorpecente. Também é o caso de aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, inobstante a condição de reincidente do réu (a condenação anterior que registra é pela prática de furto). Isso porque essa circunstância será considerada para agravar a pena do réu na segunda etapa. Assim, sua utilização para negar a diminuição da pena acaba constituindo bis in idem, não autorizado pelo ordenamento jurídico, que rechaça a possibilidade da mesma circunstância ser utilizada por mais de uma vez para agravar a situação do agente. Além disso, o STJ já decidiu que a reincidência, por si só, não afasta o "tráfico privilegiado": "A ínfima quantidade da droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo perfeitamente cabível a sua aplicação em patamar intermediário (1/2), diante da reincidência" (HC 660.930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Dessa forma, nada impede que seja reduzida a pena do réu, ainda que não seja no patamar máximo. E com o reconhecimento da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se possível, por consequência, a fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, requer-se seja conferido ao acusado o direito de apresentar eventual apelação em liberdade.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do acusado JOANDERSON, foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). conforme restou demonstrado após a fase de instrução não há elementos suficientes para ensejar a condenação do réu JOANDERSON CORREA NOVA, devendo a ação penal ao final ser julgada IMPROCEDENTE quanto ao crime tipificado no art.33, caput, desclassificando-se sua conduta ao previsto no art.28, ambos da Lei nº11.343/2006. DA PROVA ORAL COLHIDA A testemunha policial ROBERTO CARLOS ROCHA, disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento pelo bairro, e o local que realizaram a abordagem já é conhecido como ponto de tráfico de drogas, já tendo inclusive realizado algumas prisões em flagrante na quele local. Os dois indivíduos tentaram empreender fuga após, entretanto obtivemos êxito em realizar a abordagem os quais identificados se tratavam de JOANDERSON E GIOVANI. Com GIOVANI foram

localizadas bastante porções de COCAÍNA, e também dinheiro já em notas trocadas. Com o outro indivíduo foi localizado uma bolsa a qual continha pouca quantidade de pinos de COCAÍNA e também algumas porções de maconha. Indagados confessaram informalmente que estariam na prática do tráfico de drogas, sendo GIOVANI o responsável pelo ponto de tráfico e JOANDERSON como seu primeiro dia de venda no local. Indagado pela defesa, respondeu que somente cientificou o réu dos seus direitos constitucionais, após a suposta confissão informal do acusado. Interrogado o réu GIOVANI, disse que não é verdade os fatos aqui tratados. Que estava indo na casa de uma amiga que residia na comunidade, não estava junto com o JOANDERSON. No momento em que eu estava descendo nos abordaram e acusaram da prática de tráfico de drogas. Interrogado o réu JOANDERSON, disse que estava com 13 porções de COCAÍNA e 15 porções de MACONHA e mais cinco reais. Que a droga era para seu consumo. Eu estava descendo o escadão, e ao final do escadão GIOVANI estava no final do escadão, momento em que eu cheguei no final do escadão fui abordado junto com o GIOVANI. Não conhecia os Policiais. DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO: A suposta "confissão informal" perante os policiais no momento da abordagem não pode ser considerada, eis que não há qualquer prova de que foram respeitados seus direitos constitucionais quando da sua obtenção. Pelo contrário, o próprio Policial informou em audiência que somente deu conhecimento ao réu dos seus direitos constitucionais, de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si após a suposta confissão. Desta forma, temos que a versão apresentada pelos Policiais Militares, de que o réu teria assumido que estaria na prática delitiva de tráfico de drogas. Ademais, há de se notar que perante a Autoridade Policial o réu permaneceu em silêncio, desta forma, se tivesse sido alertado a cerca de seus direitos constitucionais durante a abordagem policial certamente teria permanecido calado também. Assim, na dúvida, se foi o réu cientificado pelos agentes da lei, a cerca do seu direito constitucional de permanecer calado e não produzir provas contra si, uma vez que houve violação ao direito constitucional do acusado, deve se reconhecer a imprestabilidade da suposta confissão informal, a respeito da origem dos valores e da suposta pr de acordo com o previsto no art.5º, LVI, da Consituição Federal e art.157 do Código de Processo Penal. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 386, VII DO CPP. Conforme restou comprovada nos autos não há indícios suficientes de autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com relação ao réu. A defesa não cabe o onus da prova e sim a acusação, e no caso dos autos a única prova contra o réu são as versões dos Policiais Militares que ao final são insuficientes para fundamentar uma possível condenação pelo crime tipificado na denúncia. É bem verdade que os depoimentos dos policiais nos processos criminais são prestigiados pela doutrina e jurisprudência. No entanto, tal prova deve ser analisada à luz das demais produzidas nos autos, UMA VEZ QUE A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TRAZ GARANTIA DE SER O MESMO CONSIDERADO INFALÍVEL EM SUAS AÇÕES, ESPECIALMENTE NAQUELAS DECORRENTES DA SUA FUNÇÃO, EXERCIDA, QUASE SEMPRE, EM SITUAÇÃO DE INTENSO ESTRESSE. A nossa Jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra, única e exclusiva de Policiais, não podem servir como única base para a condenação de inocentes: "POR MAIS IDÔNEO QUE SEJA O POLICIAL, POR MAIS HONESTO E CORRETO, SE PARTICIPOU DE DILIGÊNCIA, SERVINDO DE TESTEMUNHA, NO FUNDO ESTÁ PROCURANDO LEGITIMAR SUA PRÓPRIA CONDUTA, O QUE JUDICIALMENTE NÃO É ADMISSÍVEL. A LEGITIMIDADE DE TAIS DEPOIMENTOS SURGE, POIS, COM A CORROBORAÇÃO POR TESTEMUNHAS ESTRANHAS AOS QUADROS POLICIAIS. (TACRIM/SP-AC 135.347-3- REL.& JUIZ CHIARANDIA NETO)" - "TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA PRECÁRIA, RESULTANTE APENAS DE DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI Nº 6368/76. A CONDENAÇÃO EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA. QUANDO O SUPORTE DA ACUSAÇÃO ENSEJA DÚVIDAS, O MELHOR É ABSOLVER. (TARJ-REL. ERASMO COUTO- RT 513/479, in ibdem, p. 2.048)". - "POLICIAIS NÃO ESTÃO, Á EVIDÊNCIA, IMPEDIDOS DE DEPOR, MAS A JURISPRUDÊNCIA TEM CONSIDERADO MANIFESTADAMENTE SUSPEITOS NOS DEPOIMENTOS, SEMPRE QUE EXCLUSIVOS, EM CASOS ESPECÍFICOS DE PORTE DE ENTORPECENTES, EMBORA POSSAM ELES, FACILMENTE, CONVOCAR PESSOAS ALHEIAS AOS QUADROS DA POLÍCIA PARA TESTEMUNHAR O FATO (TJSP- RT- 609/524)". - "TESTEMUNHO DE POLICIAL INTERESSADO EM DEFENDER A LEGALIDADE DOS ATOS QUE PRATICA ENVOLVENDO SUSPEITO. O POLICIAL TENDERÁ EM DEPOR

CONTRA O INDICIADO POIS, CASO PROCEDA AO CONTRÁRIO, ESTARÁ ADMITINDO A PRÁTICA DO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. DONDE NÃO SE PODE CONDENAR APENAS COM BASE NESTES TESTEMUNHOS. (TRACRIM/SP- 5º CÂMARA- AC 3349.803)" - AS PALAVRAS DOS POLICIAIS MERECEM CREDIBILIDADE, MAS NÃO BASTA O TÍTULO (EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE POLICIAL). HÁ NECESSIDADE DE QUE ESTAS TENHAM APOIO EM EVIDÊNCIAS CIRCUNSTANCIAIS E TESTEMUNHAIS, SOB PENA DE EXALTAR-SE UM REGISTRO INDICIÁRIO COMO ABSOLUTO, INFALÍVEL E INQUESTIONÁVEL. (TJSP- 7ª CÂMARA CRIMINAL- AP. CR. N. 1465.651/6 COM. DE CAMPINAS J. 19/05/2005- V.U.) - ENTORPECENTES- TRÁFICO- PROVAS SUFICIENTES- NÃO COERÊNCIA- CONDENAÇÃO- IMPOSSIBILIDADE- AS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES APESAR DE IDÔNEAS NÃO PODEM SERVIR PARA A CONDENAÇÃO QUANDO NENHUMA OUTRA PROVA DOS AUTOS LHE DEEM SUPORTE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDA.(APELAÇÃO N. 990.09.181.450-4 RELATOR DESEMBARGADOR PEDRO MENIN 16/03/2010) "(...) SÓ A PALAVRA DOS POLICIAIS NÃO É SUFICIENTE PARA CONSIDERAREM-SE PLENAMENTE PROVADOS OS FATOS, NA SUA AUTORIA. NAS AÇÕES PERSECUTÓRIAS, DE COMBATE AO CRIME, MORMENTE O TRÁFICO DE TÓXICOS, NÃO SE PODE EXIGIR HAJA MODELOS DE PROCEDIMENTOS REPRESSIVOS. MAS, COMO TAIS PROCEDIMENTOS VISAM POSSIBILITAR INCLUSIVE A AÇÃO PENAL, À TODA EVIDÊNCIA DEVAM OS POLICIAIS PROCURAR A PRODUÇÃO DE PROVAS IDÔNEAS, PARA ÊXITO NA FUTURA DELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SE NÃO AS CONSEGUEM, LAMENTA-SE, MAS NEM POR ISSO PODE E DEVE O JUIZ SUPRI-LAS (ATÉ PORQUE NÃO É DE SUA FUNÇÃO), COM A ADOÇÃO DE RACIOCÍNIOS HIPOTÉTICOS. RECONHECE-SE, PORTANTO, QUE A PERSECUÇÃO POLICIAL NÃO TEVE A EFICÁCIA OPERACIONAL APTA A CONFERIR IDONEIDADE À ACUSAÇÃO (...)" (TJSP. 7ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL. APELAÇÃO 990.08.178877-2. RELATOR DESEMBARGADOR CLÁUDIO CALDEIRA. JULGAMENTO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2010). - NÃO HÁ ÓBICE LEGAL PARA A ACEITAÇÃO DA PALAVRA DE POLICIAIS COMO TESTEMUNHO VÁLIDO A APOIAR A TESE ACUSATÓRIA. NO ENTANTO, HÁ PERIGOSA TENDÊNCIA NO SENTIDO DE ADMITIR COMO SUFICIENTE A PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. QUALIFICAMOS COMO PERIGOSA PORQUE COM TAL EXPEDIENTE A RESPONSABILIDADE SOBRE O QUE OCORREU ESCORREGA DAS MÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E PASSA A PERTENCER AOS POLICIAIS, QUE PASSAM A TER O FUTURO DAQUELES QUE CAPTURARAM EM SUAS MÃOS. NÃO SE TRATA DE PRESUMIR QUALQUER INIDONEIDADE NA PALAVRA DA POLÍCIA, QUE, EM REGRA TEM AGENTES HONESTOS E PREPARADOS, MAS SIM IMPEDIR A CUMULAÇÃO DESMEDIDA DE PODER NA MÃO DE QUALQUER AUTORIDADE PÚBLICA. NÃO SE PODE PERMITIR QUE A SIMPLES VERSÃO HARMÔNICA DE DOIS POLICIAIS, COMPANHEIROS DE TRABALHO, SEM QUALQUER OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO, PERMITA A CONDENAÇÃO. VALE LEMBRAR QUE HÁ VÁRIAS PROVAS VIÁVEIS, COMO TESTEMUNHOS DE TERCEIRO, EVENTUAIS COMPRADORES, PROVAS PERICIAIS QUE DEMONSTREM CONTATO DO ACUSADO COM A DROGA, FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, GRAVAÇÕES. TAIS PROVAS APENAS NÃO SÃO PROVIDENCIADAS PORQUE, NO ENTENDER DOS PRÓPRIOS AGENTES DO APARELHO PERSECUTÓRIO, ELAS SÃO DESNECESSÁRIAS, POIS BASTA A "SACRALIZADA" PALAVRA DOS POLICIAIS. TAL SUPERVALORIZAÇÃO ACABA POR ESTIMULAR, NO MÍNIMO, O POUCO EMPENHO DA COLETA DE PROVAS, POIS OS POLICIAIS JÁ SABEM SUFICIENTES SEUS PRÓPRIOS TESTEMUNHOS, SEMPRE PASSÍVEIS DE ERRO E, NO MÁXIMO, A PROLIFERAÇÃO DE FLAGRANTES FORJADOS E EXTORSÕES, SEM COMENTAR AS CONDENAÇÕES INOCENTES. ASSIM SEM SUB VALORIZAÇÃO, SOMOS CONTRA A SUPERVALORIZAÇÃO DOS REFERIDOS TESTEMUNHOS" (JUNQUEIRA, GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ; FULLER, PAULO ARANDA. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. V. 1. 4ª ED. SÃO PAULO: PREMIER MÁXIMA, 2007, P. 233-234). (NEGRITO E GRIFO NOSSO).Como se sabe, no processo criminal tudo deve ser cabalmente provado, sem nenhuma sombra de dúvida, os fatos devem ser realmente esclarecidos, em todos os seus detalhes e circunstâncias, nada pode ser presumido. Na ausência de certeza quanto à autoria do delito, vigora o princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida, resultado da insuficiência de provas, deve ser sempre interpretada em benefício do réu, devendo o mesmo ser ABSOLVIDO do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, acordo com o art.386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda restar suficiente comprovada a autoria e materialidade do delito, requer a APLICAÇÃO DO ART. 33, §2º, "B" do CÓDIGO PENAL, possibilitando o início

do cumprimento de pena em regime intermediário, SEMIABERTO, bem como o direito de recorrer da sentença em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

GIOVANI MATHEUS GONÇALVES e JOANDERSON CORREA NOVA, qualificado nos autos, foram

denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 00,50 horas, na Rua Lins nº 209, Bairro Jardim Itapua, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, previamente ajustados, traziam consigo, para fins de tráfico, 6,9g de cocaína, distribuídos em 23 eppendorfs, 24,7g da mesma droga, distribuídos em 108 eppendorfs, e 44,6g de Cannabis sativa L., distribuídos em 46 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que no dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local acima mencionado, ocasião em que avistaram os acusados, os quais notaram a presença policial e empreenderam fuga a pé. Em razão disso, foram perseguidos e abordados. Em revista pessoal, na posse de Giovani, foram localizados 108 eppendorfs de cocaína, um celular e a quantia de R\$90,00, proveniente do narcotráfico, enquanto com Joanderson encontraram 23 eppendorfs de cocaína, 46 invólucros de maconha e a importância de R\$ 49,00, oriunda da mercancia ilícita. Conclui a denúncia que todas as drogas pertenciam aos réus e se destinavam ao narcotráfico.

Os réus foram notificados nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 156/158). Defesas preliminares apresentadas às fls. 162/164 (Joanderson) e fls. 177/178 (Giovani). Após, a denúncia foi recebida (fls. 180) e os réus foram citados às fls. 235/237.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

As Defesas pediram a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência de fls. 09/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/17, fotografias de fls. 36/44, laudo de constatação de fls. 19/21 (com cópia as fls. 141/143) e laudo de exame químico toxicológico de fls. 183/184, ambos com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 06/08), os réus permaneceram em silêncio.

Interrogado em juízo (gravação), Giovani negou o crime. Disse que, no dia dos fatos, estava passando pelo local, em direção à casa de uma amiga que mora na comunidade, quando foi abordado pelos policiais. Joanderson foi abordado na mesma oportunidade, mas não estavam juntos. Admitiu portar apenas 3 gramas de maconha, para seu uso, e R\$ 90,00 em dinheiro. Disse que tinha emprego fixo numa fábrica de sofá na cidade de Rio Claro. Negou traficar.

No interrogatório judicial (gravação), o réu Joanderson também negou o crime.

Declarou que, no dia dos fatos, comprou em outro ponto de tráfico, 13 porções de cocaína e 15 de maconha, para seu uso, pagando R\$ 205,00. Trazia consigo, além das drogas, mais R\$ 5,00. Estava descendo o escadão, o qual usava como trajeto para sair e entrar na comunidade onde morava, quando viu Giovani por lá. Ambos foram abordados pelos policiais. Disse que trabalhava e costumava comprar maior quantidade de drogas para não precisar ir no ponto de tráfico todos os dias. As drogas que portava durariam em torno de 4 dias.

As negativas foram afastadas pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Roberto Carlos Messias declarou que, na data dos fatos, estava com seu parceiro de farda em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Itapua e, quando passaram pelo local dos fatos, conhecido ponto fixo de venda de drogas, depararam-se com os dois acusados, os quais, ao notarem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga a pé. Após breve acompanhamento, ambos

foram abordados e identificados. Com Giovani foram localizados 108 porções de substância análoga de cocaína (embalada em pinos verdes) e a quantia de R\$ 90,00 em notas trocadas. Na posse de Joanderson, dentro da bolsa que ele trazia consigo, foram encontrados 23 invólucros, de cores preta e rosa, contendo cocaína, 46 porções de maconha e R\$ 49,00 em notas trocadas. Indagados separadamente, ambos confessaram a prática do narcotráfico, sendo que Giovani se identificou como "patrão" e Joanderson disse que era o primeiro dia que estava trabalhando para o corrêu. Esclareceu que o comércio ilegal de drogas naquele ponto é muito intenso, explicando que já fez diversas prisões em flagrante por tráfico naquele local e, quando voltam ali no próximo turno, já tem outro traficante atuando no mesmo ponto. Informou que, de 150 a 200 metros do local dos fatos, há uma escola e uma das maiores reclamações da diretora era a ocorrência de tráfico de drogas naquele ponto, onde havia um escadão que funcionava como um dos principais acessos da rua para o interior da comunidade Pantanal, sendo passagem dos alunos que estudavam na escola e moravam no interior da comunidade. Disse que não conhecia o réu Joanderson e, quanto ao réu Giovani, já o havia visto no local dos fatos, mas nunca o havia abordado.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 05) pelo policial militar Gilmar Pereira da Costa.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro

FELIX FISCHER – j. 23/10/2018) g.n.

“Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.” (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO – j. 11/09/2020) – g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSO JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação dos acusados em detrimento da palavra dos policiais: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daqueles é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que os réus traziam consigo, para fins de tráfico, as drogas descritas na denúncia, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, suas negativas foram afastadas pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de ambos estavam postados em conhecido ponto de venda de drogas e esboçaram reação de fuga ao notarem a aproximação da polícia. Alcançados e abordados, na posse de ambos, foram encontradas grandes quantidades de drogas diversas e dinheiro em notas trocadas.

Evidente, portanto, que portavam os entorpecentes para fins de tráfico.

A expressiva quantidade, incompatível com a situação de meros usuários, a existência de variedade de entorpecentes, o fato de estarem embalados individualmente, como, comumente são comercializados, aliados ao fato de os réus portarem dinheiro em notas trocadas sem comprovarem a origem lícita, e ao fato de estarem parados no ponto de tráfico e terem esboçado reação de fuga ao notarem a aproximação da polícia, não deixam dúvidas do destino mercantil dos entorpecentes. Registro, aqui, que a confissão informal não foi considerada como elemento de convicção para a comprovação do tráfico, de modo que fica afastada a arguição da defesa de que houve prova ilícita e nula porque aos réus não foi dado o direito ao silêncio por ocasião da oitiva informal feita pelos policiais.

Sobre a viabilidade dos demais elementos considerados pelo juízo demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas – Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas.

Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020). Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A existência de diversidade de drogas e a quantidade, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiram à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Não se faz presente nenhuma circunstância atenuante.

Por outro lado, os dois réus têm contra si a agravante da reincidência (condenações definitivas nos processos criminais nº 1636-57.2017, fls. 50, Giovanni e nº 28275-47.2012, fls. 57/58, Joanderson), o que enseja o aumento das reprimendas em 1/6, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento das penas corporais, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, estes também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada, pois indicam que os réus vem

reiterando em práticas delitivas.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que os réus sentissem as consequências de seus graves atos.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, em casos como esse. Confira-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Revisão criminal - Tráfico de drogas e Trazer arma consigo sem licença - Art. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 19 da Lei de Contravenções penais - Absolvição quanto ao crime de tráfico - Ausência de decisão contrária à prova dos autos - Robusto conjunto probatório - Narrativas dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam o encontro de drogas com o peticionário - Tais depoimentos não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa a ele - Ademais, a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos - Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do acusado, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos. E esse não é o caso dos autos, pois a prova colhida no decorrer da instrução resultou suficiente para a prolação de decreto condenatório - Reincidência devidamente demonstrada, o que torna incogitável aplicar o redutor - Regime fechado inalterado, tendo em vista a presença da recidiva do acusado - Pena maior de quatro anos, o que impossibilita a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos - Pedido indeferido". (TJSP - Revisão Criminal 2031611-39.2020.8.26.0000. 4º Grupo de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 29/09/2020) - g.n.

Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios aos acusados e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Anoto que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP,

porquanto os réus estão presos a menos de três meses, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas dos réus.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO o réu GIOVANI MATHEUS GONÇALVES a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06

2) CONDENO o réu JOANDERSON CORREA NOVA a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que as quantias apreendidas são decorrentes do tráfico, pois estavam na posse dos réus junto com as drogas, em ponto de tráfico, e não há comprovação da origem lícita, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, os réus são reincidentes e com eles foi apreendida considerável quantidade de drogas, para fins de tráfico, atividade nefasta que estavam exercendo, o que indica incompatibilidade com a vida em sociedade e real possibilidade de reiteração criminosa a justificar a manutenção da prisão preventiva, necessária para garantia da ordem pública.

Mantenho, assim, a prisão preventiva dos acusados. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelos RÉUS Joanderson e Giovani e suas DEFESAS foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA da acusação ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para o MP.

Recebo os recursos interpostos. Desde já sai a defesa do réu Joanderson intimada do prazo para apresentação das razões de apelação, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento.

Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia